

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2019.0000165967

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000998-54.2015.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante V. DE M. C. T., é apelado D. DE M. DA S. (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, é que negaram provimento ao recurso, com observação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAIA DA CUNHA (Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

Maia da Cunha
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4ª Câmara de Direito Privado

APELAÇÃO Nº : 0000998-54.2015.8.26.0450
APELANTE : V. de M. C. T.
APELADA : D. de M. da S. (Assistência Judiciária)
COMARCA : Piracaia
JUIZ : Carlos Henrique Scala de Almeida
VOTO Nº : 45.701

Fixação de guarda. Ação proposta pela avó materna contra a genitora dos menores. Situação de fato em que as crianças residem com a avó desde o seu nascimento. Caso de difícil solução, em que por ocasião de investigação de paternidade e realização de exame de DNA, comprovou-se que o esposo da autora é genitor dos cinco menores, respondendo a processo crime por estupro contra a requerida, conjuntamente com a avó materna, que responde por omissão. Atual esposo da ré e padrasto das crianças, contudo, acusado de estuprar as duas filhas menores, à época com oito e dez anos, e condenado em primeira instância a oito anos de prisão. Análise do conjunto probatório, notadamente os estudos psicossociais realizados por psicóloga e assistente social do juízo, que apontam para a manutenção da situação de fato vivida pelas crianças, com a concessão da guarda à avó materna, observando-se a necessidade de acompanhamento constante do Conselho Tutelar ao núcleo familiar. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de guarda c.c. alimentos, sustentando a ré, em suma, que os laudos psicossociais realizados revelaram que os menores foram submetidos a processo de alienação parental pela autora, avó materna das crianças, não se podendo olvidar, ainda, que tanto a autora quanto o seu atual esposo estão respondendo por múltiplos estupros praticados contra a ré, filha da requerente e mãe dos menores, não se podendo conceder a guarda a quem se omitiu, permitiu e consentiu com o estupro da própria filha. Argui, desse modo, que a melhor solução seria a concessão da guarda a uma terceira pessoa da família, até que os menores possam voltar a ter convívio com a genitora.

O apelo foi julgado em 29.06.2017, tendo sido anulado pelo acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, arguindo nulidade insanável diante da ausência de oportunidade para se manifestar no feito (fls. 187/205).

Às fls. 210/212 a douta Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4ª Câmara de Direito Privado

opinou pelo improvimento do recurso.

Este é o relatório.

O recurso não merece provimento.

O caso é de difícil solução, considerando que o marido da requerente, avó materna dos menores, foi reconhecido como pai das cinco crianças por exame de DNA realizado em ação de investigação de paternidade, tendo sido acusado em processo criminal por estupro à requerida, mãe das crianças e filha da autora. De outro lado, o esposo da ré, padrasto das crianças, foi condenado em processo já transitado em julgado por estupro às duas filhas da requerida, M. e S.

A relação de beligerância entre as partes é evidentes, e tanto a assistente social quanto a psicóloga do juízo afirmaram haver altos indícios de alienação parental pela autora, que detém a guarda de fato das crianças pelo menos desde 2011, quando a genitora dos menores deixou a residência de sua mãe, casou-se e passou a residir com o atual esposo.

E os menores, entrevistados pelas profissionais do juízo para elaboração do parecer técnico, foram unânimes em demonstrar afeto pelo avô/pai e avó materna, com quem residem desde o nascimento, e insegurança quando tratam da mãe e do padrasto, afirmando não possuir mais laços afetivos com a genitora e se recusando a ficar sob sua guarda.

A avaliação psicológica realizada pela psicóloga do juízo ponderou o seguinte: *“Não é possível a concessão de guarda para a genitora, devido ao processo que seu esposo, Sr. W., foi julgado culpado em suposto abuso sexual de M. e S., que está em recurso. Além disso, com a alienação parental avançada, a aproximação entre genitora e filhos necessita ser gradativa e acompanhada por profissional. Conclui-se que existem fortes indícios de que L., T., S., M. e D. estejam sendo alienados pela Sra. D., em relação à genitora. Assim, por definição, há forte vínculo entre a Sra. D. e seus netos, mas estes precisam ser trabalhados em terapia, visto que se trata de um vínculo não saudável, pois alienação parental encontra-se em seu estágio mais avançado. Nesses casos, o ideal seria a guarda a uma terceira pessoa da família, mas como não foi encontrada, no momento sugiro, respeitosamente, que as crianças/adolescentes permaneçam com a Sra. D., sendo imprescindível que eles (alienador e alienados) se submetam a tratamento psicológico intenso, acompanhamento da rede socioassistencial e seja garantida a distância do avô paterno/pai, Sr. M., em investigação de suposto estupro contra V., que exerceu função de pai desde seus quatro anos de idade e que tem exercido atualmente a função paterna das crianças/adolescentes”* (fl. 89).

No mesmo sentido foi o parecer da assistente social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4ª Câmara de Direito Privado

do juízo: “Os adolescentes tem garantidos seus direitos básicos, como moradia, alimentação, educação, lazer, entretanto, sob a guarda da avó parecem ser vítimas de violência psicológica que está afetando a convivência familiar e compreensão de papéis familiares, existe inversão de papéis sociais e sexuais, uma vez que para eles, a figura de homem representada pelo avô ‘é bom’ por ser o provedor e não há o reconhecimento da violência sexual. Do ponto de vista técnico, apesar de sabermos os prejuízos da alienação parental às crianças e adolescentes, neste caso específico atentamos para o fato de alto grau da alienação e outros fatores presentes (violência sexual, reconhecimento de paternidade), por isto, consideramos que haverá maior prejuízo para estes adolescentes se houver a inversão da guarda para a genitora em pouco tempo, sem preparação e tempo necessários para viabilizar a reaproximação com a genitora. Com a finalidade desta reaproximação, será necessário um acompanhamento profissional para estes adolescentes, psicológico e pela rede socioassistencial, assim como para a avó e a genitora, passível de avaliação constante pela equipe técnica. Ressaltamos o fato de que no momento os adolescentes não podem permanecer com a genitora, pois seu companheiro também está sendo processado por violência sexual contra S. e M., filhas de V. Sugerimos respeitosamente a manutenção da guarda pela avó até serem realizados os acompanhamentos e ações necessárias à reaproximação com a genitora, visto que não identificamos outros familiares com condições de exercer a guarda, pois as tias também estão envolvidas nos conflitos familiares e têm a mesma orientação sobre o assunto. Sugerimos no presente momento, o afastamento do avô/pai compreendendo que devido à suposta violência sexual praticada pelo mesmo possa apresentar um fator de risco para os adolescentes” (fls. 107/108).

Assim, embora lamentável o reconhecimento de alienação parental praticada pela avó materna, não se pode olvidar da situação de fato vivida pelas crianças, que desde o seu nascimento residem com a avó e foram criados por ela. Anote-se que, conforme consulta ao andamento processual do site do TJSP, o marido da autora encontra-se preso no processo criminal de que é réu pelo crime de estupro contra a requerida.

No mais, não obstante a ação criminal contra o esposo da genitora dos menores ainda não tenha transitado em julgado, a ação foi julgada procedente e, em consulta ao SAJ, verificou-se que foi negado provimento à apelação interposta pelo réu, por maioria de votos, sendo que divergência se limitou, apenas, ao regime inicial de cumprimento da pena de oito anos de reclusão fixada pela sentença.

E, embora com razão a apelante ao sustentar que a melhor solução da controvérsia seria a concessão da guarda a uma terceira pessoa da família, sem demonstrar desejo pela concessão da guarda em seu favor, não apontou qualquer familiar ou pessoa próxima capaz de assumir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4ª Câmara de Direito Privado

guarda dos menores, tendo a assistente social e a psicóloga do juízo afirmado não terem identificado qualquer parente ou pessoa próxima em condições de exercer a guarda.

Nada impede que a requerida, porém e se assim desejar, ajuíze ação de regulamentação de visitas, a fim de resgatar a aproximação e os laços de afinidade existentes entre mãe e filhos, gradativamente, mormente considerando a imprescindibilidade da convivência materna.

Por fim, mantem-se os alimentos tais como fixados pela sentença, considerando que a ré não se insurgiu contra a obrigação alimentícia e a pensão fixada.

Destarte, buscando resguardar os laços de afinidade das crianças com a avó materna, revela-se prudente, no momento, a fixação da guarda à requerente, conservando a situação de fato existente desde o nascimento dos netos, com a observação de que é recomendável a manutenção do constante acompanhamento do Conselho Tutelar, que atende o núcleo familiar desde 2008 diante dos conflitos existentes (fl. 136), principalmente na hipótese de vir o pai/avô das crianças a novamente residir com a requerente, por ocasião de sua liberdade. Não se pode olvidar que a autora também é ré no processo crime cuja vítima é a requerida, respondendo por omissão ao suposto crime de estupro praticado por seu esposo, ainda não sentenciado.

Daí porque o recurso não merece provimento, com observação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, porquanto já fixados no limite máximo legal permitido (20% do valor da causa).

Pelo exposto, é que se nega provimento ao recurso, com observação.

MAIA DA CUNHA
RELATOR